

1500795-22.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... em juízo, disse que tem passagem por tráfico de drogas e que foi condenado a cinco anos. Em referida oportunidade realmente estava traficando drogas em frente a sua residência, no mesmo local apurado nestes autos.

Quanto aos fatos tratados neste expediente, negou a prática do tráfico de drogas, asseverando que apenas estava no local perto de Guilherme. Na ocasião ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500795-22.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500795-22.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2112928/2022 - DEL.POL.JUQUITIBA, 24549676 -

DEL.POL.JUQUITIBA, 2112928 - DEL.POL.JUQUITIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DE ANDRADE TELES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

GUILHERME DE ANDRADE TELES e LUCAS JACOB DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, conforme os fatos narrados na denúncia à qual me reporto (fls. 186/187).

Oferecida a denúncia (fls. 187), esta foi recebida (fls. 188) e os requeridos citados.

Após a apresentação de defesas escritas (fls. 224/230 e 237/248) o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 258).

Durante a instrução, foram inquiridas testemunhas e interrogados os acusados.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes, em alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente reitero o indeferimento do pedido de oitiva de nova testemunha e de apresentação dos vídeos das câmeras de segurança existentes no local dos fatos, uma vez que a defesa técnica não justificou a imprescindibilidade da produção de referidas provas nem esclareceu quais fatos ou circunstâncias pretende comprovar com citadas diligências.

As preliminares arguidas na resposta à acusação apresentada pelo réu GUILHERME também não prosperaram.

Com efeito, a alegação de nulidade por inobservância do rito especial da Lei 11.343/06 não deve ser acolhida, pois o procedimento ordinário é mais amplo e possibilita rol ampliativo de testemunhas.

Ademais, o réu acima referido sequer demonstrou qualquer prejuízo que tenha experimentado por conta da adoção do rito ordinário, não sendo demais destacar que o acusado foi cientificado e acompanhou todas as fases do processo.

A propósito, o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Deveras, “A regra máxima em matéria de nulidades, de ordem material e/ou processual é de que inexistente nulidade sem prejuízo, curial e iterativamente aplicado o princípio do pas de nullité sans grief” (RJDTACRIM 5/133 - Rel. Marrey Neto).

Por isso, afasto a preliminar arguida.

E a preliminar de inépcia da denúncia, arguida na resposta à acusação, não convence.

A uma porque a matéria foi superada, já que o acusado não recorreu da decisão que ratificou o recebimento da denúncia.

Somado a isso, o fato só resta provado ao cabo da instrução penal, uma vez que, antes da produção das provas – que são aquelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório – há somente elementos informativos (com ressalva, é claro, das provas antecipadas ou irrepetíveis).

Ademais, a peça acusatória atende a todas as exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando, dessa forma, o exercício da ampla defesa e do contraditório.

A propósito, “a denúncia que descreve, ainda que sucintamente, o fato criminoso atribuído ao acusado, lastreando se em indícios mínimos de autoria intelectual que seja deve ser recebida. A comprovação do fato delituoso não pode se confundir com as provas que embasam a exordial acusatória. Recurso provido para que seja restabelecido o recebimento da denúncia” (STJ, REsp n.º 120.598-0, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 5ª Turma, DJ. 17.8.99).

De fato, “O recebimento da denúncia não importa, nem implica a formação de um juízo

prévio da procedência da imputação, bastando para tanto a existência de indícios da autoria e materialidade do crime" (RSE n.º 169.354/3, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, j. 5.3.96).

Nesse mesmo sentido: "Não há que se falar em inépcia da denúncia desde que esta contém quantum satis, os necessários esclarecimentos de forma a possibilitar aos acusados conhecimento pleno do fato delituoso que lhes é imputado, permitindo lhes defender se amplamente e fornecendo ao julgador elemento para um juízo de valor" (Habeas Corpus n.º 02/MG, 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzzini, j. 14.06.89).

Portanto, também afasto a alegação de inépcia da inicial.

Não há outras questões preliminares a apreciar.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que os acusados, de fato, praticaram o delito que lhes é imputado.

A materialidade da infração penal, bem como sua autoria, que recai sobre os réus, são indúvidas, eis que comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 32/33 e 35/37), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), pela fotografia (fls. 34), pelo laudo químico toxicológico (fls. 29/31 e 286/288), que atesta pelos resultados positivos para cocaína, pelo relatório final (fls. 181/182), bem como pela prova oral nos autos produzida.

De fato, os Policiais Militares Emerson Domingos Martins e Márcio Fernandes Belchior, quando inquiridos em juízo, disseram que receberam delação dando conta que dois indivíduos traficavam drogas no local dos fatos, sendo que um deles ficava com a droga e o outro entrava e saía de uma residência.

Diante disso foram ao local informado, o qual, embora seja movimentado, não é conhecido por ser ponto de venda de drogas. No recinto encontraram os réus e efetuaram a abordagem.

Asseveraram que, em revista pessoal, localizaram com o acusado GUILHERME as drogas apreendidas. Com o corréu LUCAS não encontraram nada de ilícito. Contudo, verificaram que LUCAS era procurado pela Justiça.

Ainda, durante a oitiva os agentes pontuaram que a fotografia de fls. 34 foi apresentada junto à delação.

E as falas dos policiais, contra quem nada se levantou, foram harmônicas e isentas de contradições relevantes, se cotejadas com os depoimentos prestados, por eles, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O

só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

"Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente da polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isto mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que o cidadão comum" (in "Jurisprudência Penal e Processual Penal", AZEVEDO FRANCESCHINI, vol. 8, pág. 386).

A testemunha Hércules de Melo Fabre, quando inquirido em juízo, disse que tem um consultório em frente ao local em que ocorreu a prisão dos réus. Não sabe nenhum fato que desabone o réu LUCAS e não tem conhecimento de que ocorre o tráfico de drogas no local.

Indagado pelo Ministério Público se não tinha ciência de que o réu LUCAS havia sido preso em frente ao seu consultório e que tal fato seria desabonador, a testemunha disse que soube da prisão levada a efeito.

E a testemunha Nelson de Oliveira, genitor do réu LUCAS, disse que na ocasião dos fatos seu filho foi preso, mas ele estava apenas conversando com o corréu.

Declarou que depois que LUCAS foi preso no ano de 2018 o réu apenas ficava em casa e não tem ciência do seu envolvimento com crimes.

O réu LUCAS, quando interrogado em juízo, disse que tem passagem por tráfico de drogas e que foi condenado a cinco anos. Em referida oportunidade realmente estava traficando drogas em frente a sua residência, no mesmo local apurado nestes autos.

Quanto aos fatos tratados neste expediente, negou a prática do tráfico de drogas, asseverando que apenas estava no local perto de Guilherme. Na ocasião Guilherme entregou a sacola que levava consigo aos policiais, os quais encontraram os entorpecentes.

O acusado GUILHERME, ao ser interrogado, disse que é usuário de cocaína. Respeitante aos fatos, confirmou que estava na posse das drogas. Contudo, os entorpecentes não eram destinados à traficância. Comprou 09 papelotes de cocaína em Embu das Artes. Consumiria as drogas em um dia e já esteve internado em razão do uso de drogas.

Declarou que LUCAS não tem nenhuma relação com os fatos. No dia dos fatos apenas parou para cumprimentar LUCAS, ocasião em que foram abordados.

Pois bem.

A imputação Ministerial, quanto à tipicidade da conduta dos acusados, é passível de acolhimento porque restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas que os réus, de fato, estavam a praticar a traficância.

Isso porque está clara a prática do que traz o tipo previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos, qual seja, o tráfico de entorpecentes, por parte dos réus, na medida em que levavam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ora, os entorpecentes, em considerável quantidade, eram levados e guardados pelos réus, que os detinham especialmente para o fim de cometer a traficância.

Os depoimentos prestados pelos policiais foram uníssonos e harmônicos ao descreverem as diligências realizadas durante o ocorrido. Por outro lado, as versões apresentadas pelos acusados não encontram qualquer respaldo nos autos,

Ademais, destaca-se que “os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Dessa forma, incontestemente a prática do tráfico de drogas pelos réus.

A versão apresentada pelos réus não encontra qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, o fato de LUCAS já ter sido preso por traficar drogas no mesmo local, somado à fotografia apresentada junto à delação e os demais elementos produzidos nos autos, corroboram a prova oral, no sentido de que os acusados estavam traficando drogas, inclusive com a divisão de tarefas.

Assim, diante dos elementos de convicção e das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o proceder dos acusados se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial acusatória, sendo suas condenações quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena.

Isso posto e considerando o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno GUILHERME DE ANDRADE TELES e LUCAS JACOB DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Na primeira fase não há nada a ser considerado.

Na segunda fase, verifica-se que o réu LUCAS é reincidente específico, conforme certidão de fls. 290/291. Por isso, agravo sua reprimenda em 1/6 (um sexto).

E, na terceira fase, de aplicação da pena, aplico ao réu GUILHERME a causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, à razão de 2/3, já que o acusado em questão é tecnicamente primário e não é portador de maus antecedentes, sem haver nos autos prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Por outro lado, quanto o acusado LUCAS não tem direito à causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não incide ao caso concreto.

Isso porque LUCAS ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas, praticada no mesmo local em que foi preso.

Tal fato demonstra que o acusado tem se dedicado à atividade criminosa, circunstância apta a afastar a possibilidade de aplicação da causa de redução em comento.

E é evidente que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram

com a traficância de forma pontual, ocasional, hipótese com a qual, repita-se, não se identifica o caso vertente.

Nesse sentido, verifique-se o seguinte trecho do excelente voto condutor prolatado pelo Excelentíssimo Desembargador Geraldo Wohlers, em v. acórdão que confirmou condenação proferida por este magistrado, na Comarca de Serrana:

“A diminuição hoje admitida pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se cuida de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”.

Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

No âmbito desta Colenda Câmara, consignou o preclaro DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que “essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder”.

A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.

É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente...

Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)”. (TJ/SP; Ap. 00033339-42.2011.8.26.0596; OJ 3ª Câmara de Direito Criminal: DJ 04/12.12) (destaquei)

Por tudo isso e se considerando sobremaneira que há provas suficientes de que se

dedica a atividades criminosas, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela.

Assim, para o acusado LUCAS, chego à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei

E, para o réu GUILHERME, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

Diante das especificidades do caso concreto, excepcionalmente considero cabível o regime ABERTO para início do cumprimento para o réu GUILHERME.

Quanto ao réu LUCAS, o regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO, diante da gravidade do delito em questão, da pena aplicada e, notadamente, da reincidência específica.

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juízes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que “diante do recrudesimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão.” Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente insuficiente.

Considerando a gravidade do crime, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do “sursis”.

Deveras, tais benefícios não são compatíveis, concretamente, com a necessária reprovação e a indispensável prevenção da conduta incriminada.

Afinal, como é sabido, a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a reprimenda aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como repreensão ao delinquente (prevenção específica).

Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar da edição da Resolução 5/2012 do Senado Federal suspendendo a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direito” do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, baseio-me no entendimento no sentido de que o art. 44 da Lei de Drogas não está suspenso, bem como de que a proibição da substituição fia-se no art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, na medida em que, mesmo se tratando de tráfico de drogas sem majorantes, a hediondez do delito não está afastada.

Não bastasse isso, é de se ter em conta que seria um verdadeiro absurdo que, concretamente, fosse a pena privativa de liberdade substituída por outra restritiva de direitos, já que isso tornaria possível que uma pessoa condenada por tal crime prestasse serviços a comunidade p.ex. em uma escola - onde fatalmente teria farta clientela - ou em um hospital, onde teria grande quantidade de substância entorpecente muito próxima.

Por isso, com a devida vênia dos que pensam diferentemente, repudio o entendimento de que, a não ser em casos específicos e isolados, tal substituição seja possível, ainda quando a quantidade de pena concretamente imposta não seja suficiente para afastar o benefício.

Impossível a fixação de valor mínimo a ser ressarcido pelo réu à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois não há informação nos autos sobre eventuais prejuízos financeiros experimentados pela sociedade.

Se a providência já não foi deferida, autorizo, agora, a destruição da droga apreendida.

Nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento de dinheiro e objeto apreendidos, se o caso.

Concedo ao acusado GUILHERME o direito de recorrer em liberdade, pois assim permaneceu durante a instrução do feito e por conta da pena aplicada.

Nego ao réu LUCAS o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme já manifestado na decisão que determinou a prisão preventiva, cujas razões tomo por empréstimo, uma vez não se verifica alteração do quadro probatório que motivou a segregação preventiva e porque ainda estão presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão.

Ademais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Nome no rol, oportunamente.

Ao defensor, apenas se nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidão, oportunamente.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA